

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4182/2550

นางบุญสุรพร บุญอินทร์
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ฎ.มาตรา 91/1 (4), มาตรา 91/2 (6)

พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ฎ.ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือ
หากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 มาตรา 3 (6)

การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้อสังหาริมทรัพย์นั้นตาม
มาตรา 3 (6) แห่ง พ.ร.ฎ.ออกตามความใน ป.ร.ฎ.ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244)ฯ ยังมีข้อยกเว้น
หลายประการที่ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร
แสดงว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้อสังหาริมทรัพย์นั้น
เป็นการขายที่เป็นทางค้าหรือหากำไรเสมอไป หากแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณา
เป็นแต่ละกรณีไป แม้คดีนี้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าโจทก์แบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดิน
ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนอันถือได้ว่าเป็นการขายตาม ป.ร.ฎ.มาตรา
91/1 (4) ที่ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้อสังหาริมทรัพย์นั้น แต่
เมื่อผู้ที่โจทก์โอนกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าวให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย
ของโจทก์ และเป็นการโอนโดยไม่มีค่าตอบแทน การโอนกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดัง
กล่าวจึงไม่ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไรตาม ป.ร.ฎ.มาตรา
91/2 (6) โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า โจทก์ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทซึ่งมารดาโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2522 จำนวน 1 ใน 2 ส่วน คิดเป็นเนื้อที่ 470 ตารางวา และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 อีกจำนวน 235 ตารางวา โดยมีได้ระบุว่าเป็นที่ดินส่วนใด เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2538 โจทก์ให้บุตรชอบด้วยกฎหมายของโจทก์เข้าถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินส่วนของโจทก์จำนวน 1 ใน 3 ส่วน โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นส่วนใด ต่อมาโจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินให้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะเงินเพิ่ม และภาษีส่วนท้องถิ่นรวมเป็นเงิน 343,200 บาท โดยเจ้าพนักงานประเมินให้เหตุผลว่า โจทก์ต้องชำระภาษีธุรกิจเฉพาะตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 ซึ่งตามมาตรา 91/1 (4) แห่งประมวลรัษฎากร ถือว่าการให้กรรมสิทธิ์รวมแก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นการขาย โจทก์อุทธรณ์การประเมิน ต่อมาคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ลดภาษีที่เรียกเก็บลง คงเหลือ 114,400 บาท โจทก์เห็นว่าโจทก์ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในการโอนกรรมสิทธิ์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ เนื่องจากเป็นการให้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินโดยไม่มีการแบ่งแยกไม่ได้ระบุว่าเป็นส่วนใด ถือว่าโจทก์ให้กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินส่วนที่ถือครองเกิน 5 ปี นับแต่วันที่โจทก์ได้ที่ดินมา ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เลขที่ สภ.3 (อธ.3)/272/2547 ลงวันที่ 15 มกราคม 2547 (ที่ถูกลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547) หรือขอให้ลดค่าภาษีที่ต้องชำระเหลือเพียง 10,400 บาท

จำเลยให้การและแก้ไขคำให้การว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2522 มารดาโจทก์ได้แบ่งกรรมสิทธิ์รวม (ไม่มีค่าตอบแทน) ที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์

รวมจำนวน 1 ใน 2 ส่วน โดยที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา เท่ากับ
ถือกรรมสิทธิ์คนละ 470 ตารางวา ต่อมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 มารดาโจทก์ได้
แบ่งกรรมสิทธิ์รวมที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีค่าตอบแทนให้โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม
เฉพาะส่วนของมารดาโจทก์อีก 1 ใน 2 ส่วน โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลง
ดังกล่าวเพิ่มอีก 235 ตารางวา รวมทั้งสิ้นโจทก์ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน 705 ตารางวา
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2538 โจทก์แบ่งแยกกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีค่า
ตอบแทนให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมเฉพาะ
ที่ดินส่วนของโจทก์จำนวน 1 ใน 3 ส่วน ส่วนของบุคคลอื่นคงเดิม โดยตีราคาทรัพย์สิน
ที่โอนเป็นเงิน 5,200,000 บาท ขณะที่ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่า
ธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดิน 5,170,000 บาท เจ้า
พนักงานประเมินของจำเลยได้ตรวจสอบแล้วไม่พบหลักฐานการยื่นแบบแสดง
รายการภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40) สำหรับเดือนธันวาคม 2538 ของโจทก์ เจ้า
พนักงานประเมินมีหนังสือเชิญพบโจทก์ 2 ครั้ง แต่โจทก์มิได้ไปพบและมีได้แจ้งเหตุ
ขัดข้องแต่อย่างใด เจ้าพนักงานประเมินจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 91/15 (1) และ
91/16 (1) แห่งประมวลรัษฎากร เรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะและเงินเพิ่มเติมตาม
มาตรา 89/1 แห่งประมวลรัษฎากร สำหรับเบี่ยงปรับบังคับให้ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่
ทป.127/2546 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 โจทก์อุทธรณ์การประเมิน คณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วมีคำวินิจฉัยว่า โจทก์แบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินให้แก่
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายไม่มีค่าตอบแทนถือเป็นการขายตามมาตรา 90/1 (4) แห่ง
ประมวลรัษฎากร โดยได้โอนเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2538 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาออก
ตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหา
กำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 มีผลใช้บังคับอยู่ โดยมาตรา 3 (6) แห่งพระราช
กฤษฎีกาดังกล่าวมิได้บัญญัติข้อยกเว้นไว้ อันเป็นการแตกต่างจากพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหา

กำไร (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 มาตรา 4 (6) (ง) ซึ่งบัญญัติว่า การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตน ไม่ให้ถือว่าเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร และใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป ดังนั้น เมื่อโจทก์แบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ได้กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าวยอมเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้าหรือหากำไรตามมาตรา 3 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 โจทก์มีหน้าที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา 91/2 (6) แห่งประมวลรัษฎากร แต่เนื่องจากโจทก์ได้รับการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมมาไม่พร้อมกัน โดยที่ดินจำนวน 470 ตารางวา ในจำนวน 940 ตารางวา โจทก์ได้รับเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2522 ถือเป็นการครอบครองที่ดินเกินกว่า 5 ปี ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ส่วนที่ดินจำนวน 235 ตารางวา ใน 470 ตารางวา ได้รับเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นการถือครองเพียง 1 ปี ซึ่งการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมให้แก่บุตรจำนวน 235 ตารางวา ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นที่ดินส่วนใด จึงพิจารณาปรับปรุงรายวันตามการประเมินเหลือเพียง 1 ใน 3 ของราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของที่ดิน เป็นผลให้ภาษีตามการประเมินเปลี่ยนแปลงลดลง เป็นเงินภาษี 52,000 บาท เงินเพิ่ม 52,000 บาท และภาษีส่วนท้องถิ่น 10,400 บาท รวม 114,400 บาท คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ชอบแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้แย้งกันฟัง เป็นยุติในเบื้องต้นว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2522 มารดาโจทก์ได้แบ่งกรรมสิทธิ์รวม โดยไม่มีค่าตอบแทนในที่ดินโฉนดเลขที่ 1673 ตำบลวัดอรุณ (บางกอกใหญ่ฝั่งเหนือ) อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ให้แก่โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมจำนวน 1 ใน 2 ส่วน โดยที่ดินดังกล่าวมีเนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 40 ตารางวา เท่ากับถือกรรมสิทธิ์รวมคนละ 470 ตารางวา ต่อมาวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 มารดาโจทก์ได้แบ่ง กรรมสิทธิ์รวมที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่โจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม เฉพาะส่วนของมารดาโจทก์อีก 1 ใน 2 ส่วน โจทก์จึงได้กรรมสิทธิ์รวมในที่ดินแปลง ดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีก 235 ตารางวา รวมทั้งสิ้นโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์รวม 705 ตารางวา ต่อมาเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2538 โจทก์ได้แบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าวโดยไม่มีค่าตอบแทนให้นายสุรเชษฐ์ บุญอินทร์ บุตรชอบด้วยกฎหมายของ โจทก์เฉพาะส่วนของโจทก์จำนวน 1 ใน 3 ส่วน โดยตีราคาทรัพย์สินที่โอน 5,200,000 บาท ราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมการโอนที่ดิน 5,170,000 บาท ตามภาพถ่ายโฉนดที่ดินและบันทึกการ ประเมินราคาทรัพย์สิน โจทก์ไม่ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ต่อมา โจทก์ได้รับหนังสือแจ้งการประเมินให้ชำระภาษีธุรกิจเฉพาะ เงินเพิ่ม และภาษีส่วน ท้องถิ่นรวม 343,200 บาท ตามหนังสือแจ้งการประเมินภาษีธุรกิจเฉพาะ โจทก์ อุทธรณ์การประเมิน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยให้ลดภาษีที่เรียก เก็บลง เป็นเงินภาษี 104,000 บาท เงินเพิ่ม 104,000 บาท และภาษีส่วนท้องถิ่น 20,800 บาท รวมลดให้ทั้งสิ้น 228,800 บาท คงเหลือเรียกเก็บเป็นเงินภาษี 52,000 บาท เงินเพิ่ม 52,000 บาท และภาษีส่วนท้องถิ่น 10,400 บาท รวมเรียกเก็บทั้งสิ้น เป็นเงิน 114,400 บาท โดยให้เหตุผลว่าเนื่องจากโจทก์ได้รับแบ่งกรรมสิทธิ์รวมใน ที่ดินมาไม่พร้อมกัน โดยจำนวน 470 ตารางวา ใน 940 ตารางวา ได้รับมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2522 เป็นการถือครองที่ดินเกินกว่า 5 ปี ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจ

เฉพาะ และจำนวน 235 ตารางวา ใน 470 ตารางวา ได้รับมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2538 เป็นการถือครองเป็นเวลา 1 ปี ซึ่งในการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมให้แก่บุตรจำนวน 235 ตารางวา ไม่สามารถระบุว่าเป็นที่ดินส่วนใด จึงพิจารณาปรับปรุงรายรับตามการประเมินลงเหลือเพียง 1 ใน 3 ส่วนของราคาประเมินทุนทรัพย์เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมของกรมที่ดิน เป็นผลให้ภาษีตามการประเมินเปลี่ยนแปลงลดลงตามคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

มีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า การที่โจทก์แบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีค่าตอบแทน เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้ำหรือหากำไรซึ่งอยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะหรือไม่ โดยจำเลยอุทธรณ์ว่า มาตรา 3 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 มิได้บัญญัติยกเว้นกรณีโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยไม่มีค่าตอบแทน จึงถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้ำหรือหากำไร เพราะเข้าลักษณะขายอสังหาริมทรัพย์ไปภายใน 5 ปี นับแต่ได้มา ส่วนมาตรา 4 (6) (ง) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 ซึ่งบัญญัติว่าการโอนอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนไม่ให้ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้ำหรือหากำไร มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2542 เป็นต้นไป ย่อมไม่มีผลย้อนหลังไปถึงกรณีของโจทก์ด้วยนั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นว่า การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นตามมาตรา 3 (6) แห่งพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 ยังมีข้อยกเว้นหลายประการที่ไม่เข้าลักษณะเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้ำหรือหากำไร แสดงว่าการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้มามีใช่เป็นการขายที่เป็นทางค้ำหรือหากำไรเสมอไป หากแต่เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องพิจารณาเป็นแต่ละกรณีไป แม้คดีนี้ข้อเท็จจริงจะรับฟังได้ว่าโจทก์แบ่งกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนอัน

ถือได้ว่าเป็นการขายตามประมวลรัษฎากร มาตรา 91/1 (4) ที่ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้ออกรับสิทธิครอบครองที่ดินนั้น แต่เมื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าวให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ และเป็นการโอนโดยไม่มีค่าตอบแทน การโอนกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินดังกล่าวจึงไม่ถือเป็นการขาย อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางคำหรือหากำไร ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 (6) โจทก์จึงไม่จำเป็นต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(วีระศักดิ์ เสรีเศวตรัตน์-ธีระวัฒน์ ภัทรานวัช-ชัช ชลวร)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำว่า "ขาย" ในแง่ภาษีธุรกิจเฉพาะนั้น ประมวลรัษฎากร มาตรา 91/1 (4) ได้บัญญัติให้หมายความรวมถึงสัญญาจะขาย ขายฝาก แลกเปลี่ยน ให้ ให้เช่าซื้อ หรือจำหน่ายจ่ายโอน ไม่ว่าจะมิใช่ประโยชน์ตอบแทนหรือไม่ ฉะนั้น คำว่า "ขาย" ในแง่ภาษีธุรกิจเฉพาะจึงมีความหมายกว้างกว่าคำว่า "ขาย" ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ดังนั้น การให้โดยเสน่หาหรือการแบ่งกรรมสิทธิ์รวมให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่มีค่าตอบแทนจึงถือเป็นการขายตามประมวลรัษฎากร มาตรา 91/1 (4) ดังกล่าว แม้จะ

ไม่ถือเป็นการขายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม อย่างไรก็ตาม ใ้การที่การขายที่
จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะต้องเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหา
กำไรตามที่บัญญัติไว้ในประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 (6) กรณีอย่างไรจึงจะถือ
เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรนั้นประมวลรัษฎากร มาตรา
91/2 (6) ได้บัญญัติให้อำนาจรัฐบาลกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไข แต่การ
กำหนดนั้นก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่เห็นได้ว่าเป็นการขายเป็นทางค้าหรือหากำไร เพราะ
ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 (6) ซึ่งเป็นกฎหมายแม่ กรณีที่จะต้องเสียภาษี
ธุรกิจเฉพาะจะต้องเป็นการขายเป็นทางค้าหรือหากำไรเท่านั้น ฉะนั้น หากมีการ
กำหนดให้กรณีที่มีใช้การขายเป็นทางค้าหรือหากำไรถือเป็นการขายเป็นทางค้าหรือ
หากำไรด้วย ย่อมเป็นการกำหนดเกินขอบเขตที่กฎหมายแม่ได้ให้อำนาจไว้ กรณีที่
กำหนดขึ้นมานั้นย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดย่อมใช้อำนาจตามพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 11 (2)
เพิกถอนได้ หากศาลปกครองสูงสุดไม่เพิกถอน ศาลภาษีอากรกลางและศาลฎีกา
แผนกคดีภาษีอากรซึ่งเป็นศาลยุติธรรมย่อมมีอำนาจตีความว่า กรณีที่พระราช
กฤษฎีกากำหนดขึ้นมานั้นไม่ถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร
จึงไม่อยู่ในบังคับจะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 (6)
ทั้งนี้ เพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ประชาชนผู้เสียภาษี รัฐบาลได้ตราพระราชกฤษฎีกา
(ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 มาตรา 3 (5) กำหนดให้การขายอสังหาริมทรัพย์ภายใน 5
ปี นับแต่วันที่ได้มาต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แม้จะเป็นกรณีที่บิดามารดาโอน
อสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดยเสน่หาหรือแบ่งกรรมสิทธิ์รวมในอสังหาริมทรัพย์ให้แก่
บุตรโดยไม่มีค่าตอบแทนก็ตามกรณีจึงเป็นการกำหนดให้ถือเป็นการขาย
อสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรโดยไม่คำนึงว่าความจริงเป็นการขายเป็นทาง
ค้าหรือหากำไรหรือไม่ เมื่อกรณีที่บิดามารดาโอนอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุตรโดย
เสน่หาไม่อาจถือเป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไร ศาลฎีกาจึงมีคำ

พิพาทศาลฎีกาที่ 10889/2546 วินิจฉัยว่า "การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้กระทำภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้อำนาจได้เป็นการขายเป็นทางค้ำหรือหากำไรเสมอไป พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นทางค้ำหรือหากำไร (ฉบับที่ 244) พ.ศ.2534 จึงได้กำหนดข้อยกเว้นไว้บางกรณี การโอนที่ดินให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายโดยเสนหามีใช้กรณีที่ทำเป็นทางค้ำหรือหากำไรจึงไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แม้จะเป็นการโอนให้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ได้อำนาจก็ตาม" คดีตามคำพิพาทศาลฎีกาที่ 4182/2550 ที่กำลังหมายเหตุอยู่นี้ก็เดินตามคำพิพาทศาลฎีกาดังกล่าว และต่อมาพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 มาตรา 4 (6) (ง) ซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันก็บัญญัติให้การโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรชอบด้วยกฎหมายของตน แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม ไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แม้จะเป็นการโอนภายใน 5 ปีก็ตาม ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นการโอนก่อนหรือหลังพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 342) พ.ศ.2541 มีผลใช้บังคับ การโอนนั้นไม่อยู่ในบังคับต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเพียงแต่อ้างตัวบทกฎหมายต่างกัน กล่าวคือ การโอนก่อนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับจะอ้างกฎหมายแม่คือประมวลรัษฎากร มาตรา 91/2 (6) โดยถือว่าการโอนดังกล่าวไม่ถือเป็นการขายเป็นทางค้ำหรือหากำไร ส่วนการโอนหลังจากพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวมีผลใช้บังคับจะอ้าง มาตรา 4 (6) (ง) ของพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม